

1501811-93.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501811-93.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501811-93.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136938/2022 - 02º D.P. GUARUJA, 25080426 - 02º D.P.

GUARUJA, 2136938 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAQUE DA SILVA CORREIA SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Isaque da Silva Correia Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 12:30 horas, na Rua Estradão, nº 1, Comunidade Prainha, Itapema, nesta cidade e comarca de Guarujá, trazia consigo, para o fim de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 42 papérolas de cocaína e 99 pedras de crack, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; além de um aparelho celular da marca Motorola e do valor de R\$ 69,50, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 6 e o auto de constatação preliminar de fls. 7. O réu foi notificado (fls. 52) e apresentou defesa prévia (fls. 56/57), que não comportou acolhimento e a denúncia foi recebida (fls. 63/64). O réu foi citado

(fls. 121).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 128/130).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 142). E encerrada a instrução, pelas partes nada foi requerido, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 138).

A representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 138/141).

Nos memoriais, a defesa requereu a improcedência da ação com a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06 - em seu patamar máximo - a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 146/157).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6, pelo auto de constatação preliminar de fls. 7, pela fotografia de fls. 20, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128/130, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado na fase policial, o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio (fls. 11).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva. Relatou que trabalha como servente de pedreiro, é estudante e reside com os pais. Na data e no local dos fatos, encontrava-se com um amigo, Éverton, e passou para cumprimentá-lo. Éverton é o indivíduo que estava vendendo as drogas. Quando a Polícia chegou ao local dos fatos, Éverton soltou a sacola e correu; o interrogando, então, pegou a sacola, escondeu-a sob sua blusa e correu também. Não confessou a traficância em momento algum aos policiais militares. Desconhece o motivo pelo qual foi levado ao Distrito Policial, sendo que Éverton é que estaria traficando. Todo o conteúdo da sacola apreendida era de propriedade de Éverton. O interrogando não é usuário de drogas. Frequenta os trilhos da Prainha ocasionalmente para jogar sinuca e futebol com os amigos (fls. 142).

E a negativa do réu em juízo não restou afastada pelas demais provas produzidas nos autos, que demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

A policial militar Bianca Rodrigues Carvalho, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em operação, acompanhada do policial Nilson de Souza, na Rua do Estradão, comunidade da Prainha; e quando chegaram ao local dos fatos, visualizaram dois indivíduos nos trilhos, que empreenderam fuga quando avistaram os policiais. Após um breve acompanhamento, a equipe logrou êxito em alcançá-los. Quando da revista pessoal de ambos, localizou sob a blusa do acusado uma sacola plástica contendo em seu interior 99 pedras de crack e 42 pinos de cocaína, além da importância de R\$ 69,50 em cédulas trocadas, e um aparelho celular da marca Motorola. Ao comandante da equipe, o policial militar Nilson de Souza, o acusado Isaque confessou que estava comercializando drogas. Com o segundo indivíduo abordado, nada de ilícito foi encontrado e ele foi liberado. O acusado Isaque foi preso em flagrante. A depoente não conhecia o local dos fatos, pois sua lotação é em Praia Grande, tampouco conhecia o acusado anteriormente aos fatos (fls. 142). E no mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Nilson de Souza

Marques. Relatou a testemunha que na data dos fatos se encontrava em uma operação na Rua do Estradão, na Prainha, conhecido ponto de tráfico de drogas; e quando se aproximaram do local dos fatos, dois indivíduos empreenderam fuga assim que avistaram a chegada da Polícia. Os indivíduos foram abordados. Um dos indivíduos era menor de 18 anos e nada de ilícito com ele foi encontrado. No entanto, com o acusado Isaque foi encontrada uma sacola preta sob sua blusa, em sua linha de cintura, e no interior da sacola havia cocaína e crack, além de um aparelho celular e de certo valor, em cédulas trocadas. O acusado confessou informalmente que estava comercializando as drogas e que o dinheiro com ele encontrado era produto da traficância. O depoente não conhecia o acusado anteriormente aos fatos (fls. 142). Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição. A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]" (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da forma de acondicionamento das drogas, do dinheiro em cédulas trocadas e do aparelho celular encontrados na posse do réu, e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do acusado, que estava em local conhecido pela venda de drogas, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória. Ainda, o comandante da operação, o policial militar Nilson de Souza Marques, afirmou, sob o crivo do contraditório, que o réu confessou informalmente os fatos narrados na denúncia, quando de sua abordagem.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo os entorpecentes, e os entorpecentes eram destinados para a entrega a consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à entrega para consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, ante a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, com alto poder viciante - 99 pedras de crack e 42 pinos de cocaína - considerando ainda que a conduta do réu atingiria um grande número de usuários, elevo em 1/6 a pena-base, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade do acusado, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, para reduzir a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 5 (anos) de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, em relação à aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o acusado preenche os requisitos legais. Trata-se de um adolescente de 18 anos de idade que apresenta a condição de primário, não possui antecedentes (fls. 24/25), e inexistem indícios de que integre organização criminosa. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução

das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, o réu trazia consigo cocaína e crack, que apesar do alto poder viciante, não foi em quantidade elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreram os fatos, a dedicação habitual do acusado à atividade criminosa, e que faz do tráfico de drogas um meio de vida. Tampouco se comprovou que o réu integra organização criminosa. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria penal aplico o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a reprimenda em 2/3, o que perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Ausentes dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu recentemente que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59, do Código Penal.

Neste sentido, a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA NA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos.

Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cumprir destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou da suspensão condicional da pena - nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal - pois não se mostram medidas suficientes e adequadas ao presente caso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Isaque da Silva Correia Santos para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial competente com a determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

Decreto o perdimento do aparelho celular apreendido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 6, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram tratar-se de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes. Oficie-se à autoridade policial competente comunicando, após o trânsito em julgado.

Em relação ao valor apreendido, decreto o perdimento em favor da União, vez que se trata de produto do tráfico de drogas. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para o cumprimento.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

P.I.C.

Guaruja, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA